

1512099-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... droga encontrada em poder do réu era para fins de tráfico.

Não há que se falar assim em desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei de Tráfico. E isso porque a conduta se amoldou perfeitamente ao núcleo do tipo descrito na denúncia, integrando de forma direta a cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes.

"A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512099-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512099-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2137290/2022 - 27º Distrito Policial - Campo Belo, BT2706-1/2022 - 27º Distrito Policial - Campo Belo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ DIOSVÂNIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 763/22

VISTOS.

JOSÉ DIOSVÂNIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas 33, caput, da Lei 11.343/06 porque consta que no dia 20 de maio de 2022, por volta da 1 h e 30 min, na Rua Iguaçu, numeral 79, Campo Belo, nesta cidade e Comarca, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 101 (cento e um) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack" com massa líquida de 36,2g (trinta e seis gramas e dois decigramas).

A denúncia foi recebida a fls. 58/59.

Defesa preliminar a fls. 91/92.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo,

duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de olheiro, aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 dando conta dos 12 supositórios contendo cocaína, dos 09 papелotes contendo maconha, e ainda dos R\$ 488,70 em dinheiro miúdo, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o Exame Químico Toxicológico de fls. 55/56, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para Maconha e Cocaína.

A autoria também é inconteste.

Os argumentos da Defensora Pública não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra o réu, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio. Ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu declarou que eu estava na campana mesmo naquele local. Eu sai da Cassimiro para beber uma água, e quando comecei a subir a escada fui abordado pelos policiais. Eles perguntaram se eu estava com drogas, eu disse que não, que estava apenas na campana. Os policiais perguntaram onde estava a droga, eu disse que não sabia, eles procuraram e encontraram. Eles disseram que a droga era minha, mas não era. Nunca fui processado antes e não conhecia os policiais.

Mesmo que a seu modo o réu confessou a autoria delitiva, mostrando-se arrependido. É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito condenatório. Mas é certo também que quando vem acompanhada das demais provas dos autos, como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

De outro giro, a tese do réu, secundada pela Defesa no sentido de que o réu seria apenas olheiro, em absoluto não convenceu.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais.

Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. No mais, o fato dos policiais terem abordado o réu novamente, tal circunstância ocorreu após os fatos, de maneira que em nada abala a tese acusatória ou mesmo a fala policial.

Desta feita, as justificativas do acusado, secundadas por sua defesa técnica, no sentido de que agia apenas como campana e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo que as provas dos autos apontam em sentido contrário, ou seja, que na ocasião a droga encontrada em poder do réu era para fins de tráfico. Não há que se falar assim em desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei de Tráfico. E isso porque a conduta se amoldou perfeitamente ao núcleo do tipo descrito na denúncia, integrando de forma direta a cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes.

“A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (curso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua

como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante. 3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem." (STJ, Habeas Corpus n. 224.849/RJ, 5ª Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, 11/06/2013)." Na hipótese dos autos a conduta do acusado não está abrangida pelo Art.37 da Lei de Drogas, devendo, por conseguinte, ser configurado o tráfico de drogas. É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante de dinheiro e drogas apreendidas em poder do réu não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que dificilmente usuários de drogas permanecem perambulando pela cidade com tamanha quantidade de drogas. Tal risco somente é assumido por traficantes, no afã de ganharem dinheiro fácil.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, o patrulhamento de rotina em razão do local em que o réu foi preso, ser conhecido como ponto de venda de drogas, a grande quantidade de droga encontrada, a forma como estava acondicionada, pronta para a venda individual, o encontro de dinheiro miúdo em poder do acusado, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Vinicius Leonel de Oliveira e Wesley Henrique Ferraz da Cruz, relataram em Juízo, em uma só voz que estávamos em patrulhamento de rotina, pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistamos alguns indivíduos, que saíram e o réu permaneceu sentado em uma escada. Optamos pela abordagem, ele confessou que estaria na campana. Porém é de nosso conhecimento de que ali naquele local, não há campana, porque é o local onde as drogas são vendidas para os usuários que passam de carro. Em buscas pelo local, cerca de um metro dele, encontramos atrás de um vaso, uma porchete contendo crack. Reconheceram o réu e não o conhecia anteriormente.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de patrulhamento de rotina, o encontro com o réu no local, sua abordagem, o encontro da droga, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova.

Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos

relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação. Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311). Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da quantidade de droga encontrada em poder do réu, o dinheiro encontrado em seu poder, sua confissão extrajudicial para os policiais, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros. Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários.

Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário, sem antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena base já fixada no mínimo legal, não pode ser mais reduzida pela confissão do agente.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem quaisquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa. Assim, considerando-se a diversidade das drogas, e capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de crack, substância que vem causando estragos de enormes montas nos jovens da sociedade, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JOSÉ DIOSVÂNIO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)

dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo e compareceu a todos os atos para os quais foi chamado. Além disso comprovou que se encontra trabalhando, sendo que fazê-lo retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA